

1500674-07.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... o que tipifica o crime de tráfico. A ação penal é procedente. Interrogado no auto de prisão em flagrante (fls. 14), o réu confessou o tráfico ilícito de drogas. Declarou que na data dos fatos, por volta das 14h30 horas, estava dormindo dentro de sua residência, que se trata de uma chácara, quando lá compareceram os policiais militares, os quais pediram autorização para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1500674-07.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099863/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 24245137 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2099863 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ PEDRO FRANCO DE LIMA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Em 25 de agosto de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos dos Provimentos CSM nº2545, 2549, 2561 e 2464/2020, e Comunicado CG nº 284/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. ODIVAL CICOTE, o(a) acusado(a) JOSÉ PEDRO FRANCO DE LIMA, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) testemunha(s) comum(ns) ROBSON DINARDI e RAFAEL OLIVEIRA SANCHES;

instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) ROBSON (00min21seg), e RAFAEL (03min30seg), bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) (07min34seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz(a): JOSÉ PEDRO FRANCO DE LIMA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo narra a denúncia, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Cinco, 584, no bairro Santa Clara II, nesta cidade foi surpreendido por policiais militares mantendo em depósito, sem autorização e para fins de tráfico, um total de 61,44g (sessenta e um gramas e quarenta e quatro centigramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente e que causa dependência física e/ou psíquica (laudo de constatação às fls. 35/39 e laudo toxicológico às fls. 73/75), bem como apreenderam em poder dele a quantia de R\$ 140,00 em dinheiro, produto do narcotráfico. Segundo se apurou, os policiais receberam chamado via COPOM que narrava uma ocorrência de violência doméstica numa chácara e que o indivíduo, de nome JOSÉ PEDRO, estava agredindo a esposa e armazenada entorpecentes na chácara, bem como uma arma de fogo. Em razão disso, foram até lá averiguar e ao se aproximarem da chácara avistaram denunciado, o qual, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para o interior da casa, sendo acompanhado e abordado. A amásia do denunciado, Franciele da Costa, estava no local. O denunciado foi revistado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Como o denunciado aparentava nervosismo, os policiais resolveram dar buscas pelo local, indo até a porteira onde avistaram o denunciado, percebendo que a grama estava meio mexida, motivo pelo qual deram buscas e localizaram 30 porções de maconha. JOSÉ PEDRO foi indagado acerca da droga e confessou que lhe pertenciam e que vendia cada porção por \$10,00. Indagado se tinha mais droga escondida dentro da casa, ele negou, mas como havia denúncias de que ele guardava arma e droga no interior da residência, retornaram lá para dar buscas, solicitando o apoio do canil, quando localizam mais quatro porções idênticas àquelas anteriormente apreendidas, quais estavam escondidas dentro de um urso de pelúcia que estava em um dos quartos da casa. No banheiro os policiais localizaram, dentro do lixo, a quantia de R\$ 140,00 em dinheiro. Nenhuma arma de fogo foi localizada, sendo que tanto JOSÉ PEDRO quanto Franciele negaram a existência de arma na casa. Franciele autorizou o ingresso dos policiais na casa e acompanhou todas as buscas. Interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou que a droga apreendida dentro da casa lhe pertencia e seria destinada a seu próprio consumo. Confessou, também, que a droga apreendida perto da porteira estava sob seus cuidados, mas pertencia a outra pessoa cujo nome preferiu não informar, sendo que estava guardando a droga para ganhar algum dinheiro. Dessa forma, o denunciado foi surpreendido pelos policiais mantendo em depósito, ao menos parte da maconha apreendida, para terceira pessoa, mediante pagamento, o que tipifica o crime de tráfico. A ação penal é procedente. Interrogado no auto de prisão em flagrante (fls. 14), o réu confessou o tráfico ilícito de drogas. Declarou que na data dos fatos, por volta das 14h30 horas, estava dormindo dentro de sua residência, que se trata de uma chácara, quando lá compareceram os policiais militares, os quais pediram autorização para entrar no imóvel porque um suspeito em fuga havia pulado no quintal. Então destrancou a porta e o portão e os policiais

entraram. Imediatamente eles passaram a fazer buscas no local e encontraram umas três (3) porções de maconha dentro do ursinho de pelúcia, as quais se destinavam a consumo pessoal. Em seguida eles vasculharam um monte de areia perto da porteira da chácara, no quintal, e localizaram cerca de trinta e quatro (34) porções de maconha. Admite que o entorpecente encontrado na areia estava sob seus cuidados, mas pertenciam a outra pessoa, que não quer identificar neste momento. Estava somente guardando a droga para "ganhar um trocado", porém, não estava realizando o comércio ilegal das porções de maconha apreendidas. Quanto ao dinheiro apreendido diz que era de sua esposa, oriundo da pensão alimentícia que ela recebe. Em Juízo, o acusado confessou a posse e propriedade da droga apreendida, inclusive que a droga se destinava a venda e também a consumo próprio. O policial militar ROBSON DINARDI, ouvido no auto de prisão em flagrante (fls. 10), e depois em juízo, declarou que na data dos fatos estava em companhia de seu colega de farda Rafael Oliveira Sanches em patrulhamento de rotina quando receberam um chamado via COPOM noticiando que o acusado, pessoa que até então não conheciam, estava agredindo a esposa e armazenando droga e arma de fogo na chácara onde reside. Deslocaram-se até o local e avistaram o acusado na porteira da chácara. O acusado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, correndo para o interior da casa, onde foi abordado. No local estava também a companheira do acusado, Franciele da Costa, que abriu a porta e autorizou o ingresso. O casal negou as agressões, mas o acusado estava muito nervoso e inquieto. Em razão disso e das denúncias de que o acusado guardava droga e arma de fogo na casa resolveram fazer uma busca chácara. Na porteira onde o acusado estava quando viu a viatura e fugiu, perceberam que a grama estava meio mexida. Assim, começaram a vasculhar no local e prontamente acharam 30 porções de maconha. Nesse momento o acusado confessou a posse e propriedade da droga, alegando que vendia cada porção por R\$ 10,00. Como havia denúncia de que na casa havia mais drogas, foi solicitado o apoio do BAEP CANIL, ocasião em que foi localizado mais 4 porções idênticas às localizadas anteriormente, escondidas em um urso de pelúcia que estava em um dos quartos da residência. No banheiro encontraram a quantia de R\$ 140,00, em diversas notas, dentro do lixo do banheiro. O policial militar RAFAEL OLIVEIRA SANCHES, ouvido no auto de prisão em flagra (fls. 12) e depois em juízo, confirmou o depoimento de seu colega de farda Robson Dinardi. Declarou que na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando receberam um chamado via COPOM noticiando que o acusado, pessoa que até então não conheciam, estava agredindo a esposa e armazenando droga e arma de fogo na chácara onde reside. Deslocaram-se até o local e avistaram o acusado na porteira da chácara. O acusado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, correndo para o interior da casa, onde foi abordado. No local estava também a companheira do acusado, Franciele da Costa. O casal negou as agressões, mas o acusado estava muito nervoso e inquieto. Em razão disso e das denúncias de que o acusado guardava droga e arma de fogo na casa resolveram fazer uma busca chácara. Na porteira onde o acusado estava quando viu a viatura e fugiu, perceberam que a grama estava meio mexida. Assim, começaram a vasculhar no local e prontamente acharam 30 porções de maconha. Nesse momento o acusado confessou a posse e propriedade da droga, alegando que vendia cada porção por R\$ 10,00. Como havia denúncia de que na casa havia mais drogas, foi solicitado o apoio do BAEP CANIL, ocasião em que foi localizado mais 4 porções idênticas às localizadas anteriormente, escondidas em um urso de pelúcia que estava em um dos quartos da residência. No banheiro encontraram a quantia de R\$ 140,00, em diversas notas, dentro do lixo do banheiro. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do delito atribuída ao réu na denúncia, a condenação se impõe. O réu é reincidente específico (1500956-16.2020.8.26.0559 – 3ª Vara Criminal): sentença condenatória com trânsito em julgado para a defesa em 24/03/2022, motivo pelo qual deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006; Ante o exposto, somos pela procedência do pedido e consequente condenação do réu JOSÉ PEDRO FRANCO DE LIMA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Requer a decretação do perdimento definitivo do dinheiro apreendido, produto do narcotráfico (total de R\$ 140,00), nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal e artigo 63 da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD. Em seguida, dada a

palavra a(o) Dr(a). Defensor(a) do acusado, o mesmo apresentou as alegações finais pelo sistema audiovisual (10min36seg). Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: “Vistos. JOSÉ PEDRO FRANCO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Cinco, 584, no bairro Santa Clara II, nesta cidade, o acusado foi surpreendido por policiais militares mantendo em depósito, sem autorização e para fins de tráfico, um total de 61,440g de maconha, substância entorpecente e que causa dependência física e/ou psíquica, bem como apreenderam em poder dele a quantia de R\$ 140,00 em dinheiro, produto do narcotráfico. Narra a denúncia que os policiais receberam chamado via Copom que narrava uma ocorrência de violência doméstica numa chácara e o indivíduo de prenome JOSÉ PEDRO estava agredindo a esposa e armazenava entorpecentes na chácara, bem como uma arma de fogo. Narra que os policiais foram averiguar, mas o acusado empreendeu fuga ao avistar a viatura, sendo acompanhado e abordado. Narra que a amásia do acusado, Franciele da Costa, estava no local. O acusado foi revistado e nada de ilícito foi encontrado com ele, contudo, como o acusado aparentava nervosismo, os policiais resolveram dar buscas pelo local, indo até a porteira onde avistaram o acusado, percebendo que a grama estava meio mexida, motivo pelo qual deram buscas e localizaram 30 porções de maconha. Indagado, o acusado assumiu a propriedade da droga, confessando que vendia cada porção por R\$ 10,00, negando que mantinha mais drogas no imóvel. Contudo, como havia denúncias de que ele guardava arma e droga no interior da residência, solicitaram o apoio do canil e, durante as buscas, localizaram mais quatro porções idênticas àquelas anteriormente apreendidas, as quais estavam escondidas dentro de um urso de pelúcia que estava em um dos quartos da casa. No banheiro os policiais localizaram, dentro do lixo, a quantia de R\$ 140,00 em dinheiro. Nenhuma arma de fogo foi localizada, sendo que tanto o acusado quanto Franciele negaram a existência de arma na casa. Franciele autorizou o ingresso dos policiais no imóvel e acompanhou todas as buscas. Notificado (fl. 97), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 102). Recebida a denúncia (fls. 104/107), foi citado. Durante a instrução, depois de ouvidas as testemunhas, o acusado foi interrogado. A instrução foi encerrada e nos debates orais o Ministério Público reiterou o pedido condenatório contido na denúncia, ao passo que a Defesa sustentou a absolvição, alegando falta de provas. É o relatório. DECIDO. Primeiro, quanto à alegada violação do domicílio, ressalto que o crime de tráfico de drogas é permanente, logo, possível o ingresso em residência, quando existirem indícios da prática de crime. Muito embora a Constituição Federal em seu artigo 5º, XI, diga ser o lar asilo inviolável, essa norma traz exceções, como na hipótese de prisão em flagrante delito, o que se verificou nesse caso. Ademais, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 05/11/2015 o Recurso Extraordinário nº 603.616, representativo da controvérsia, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, dotado de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5º, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre

tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (grifo meu). Ora, havia denúncias de três ilícitos sendo cometidos no local, havendo fundadas suspeitas de crimes sendo cometidos no local, muito bem justificadas pelos policiais nessa audiência. Aliás, em decisão recente, a Ministra Rosa Weber, assentou que "A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado" (STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 213.852/RJ, 1ª Turma, j. 30 de maio de 2022). Quanto ao mérito, na fase extrajudicial o acusado afirmou que estava dormindo dentro de sua residência quando lá estiveram presentes os policiais militares, os quais pediram autorização para entrar no imóvel porque um suspeito em fuga havia pulado no quintal. Diante disso abriu o portão, os policiais entraram e imediatamente passaram a fazer buscas no local, encontrando três porções de maconha dentro do ursinho de pelúcia, porções estas porções que se destinavam ao seu próprio consumo. Em seguida os vasculharam um monte de areia perto da porteira da chácara, no quintal, e localizaram cerca de trinta e quatro porções de maconha. Confessou que o entorpecente encontrado na areia estava sob seus cuidados, mas pertencia a outra pessoa, sendo que estava somente guardando a droga para "ganhar um trocado", negando que estivesse atuando no comércio ilegal de drogas. O dinheiro apreendido era de sua esposa, fruto da pensão alimentícia que ela recebe. Interrogado em Juízo o acusado novamente confessou a prática do crime que lhe é imputado, dizendo que realmente a droga apreendida lhe pertencia e se destinava tanto à venda como para o próprio consumo. É usuário de drogas. Estava em poder da droga há cerca de dois dias. Os policiais Robson Dinardi e Rafael Oliveira Sanches, no auto de prisão em flagrante, afirmaram que foram acionados pelo Copom sobre uma ocorrência de violência doméstica, onde o indivíduo de prenome José Pedro estava agredindo sua esposa, e ainda armazenava entorpecentes na chácara, bem como uma arma de fogo. Aproximando-se do local avistaram um homem na porteira da chácara, o qual tentou empreender fuga, mas foi detido no interior de residência, onde também estava sua amásia Franciele da Costa. Nada de ilícito foi encontrado com o acusado, mas quando questionado o casal, ambos negaram as agressões, e como o acusado apresentava nervosismo e, diante das denúncias recebidas, resolveram realizar uma busca prévia pela chácara, sendo que retornaram onde o acusado estava quando viu a viatura, e perceberam que a grama estava meio mexida, foi quando começaram a vasculhar no local e prontamente acharam 30 porções de maconha. Novamente indagado, o acusado assumiu a propriedade do entorpecente, indicando que vendia cada porção por R\$ 10,00, bem como negou que mantivesse mais drogas no local. Diante das denúncias acionaram o canil, ocasião em que localizaram mais quatro porções idênticas àsquelas anteriores, escondidas em um urso de pelúcia que estava em um dos quartos da residência. No banheiro localizaram também a quantia de R\$ 140,00, em diversas notas, dentro do lixo. Não foi localizada nenhuma arma de fogo. Franciele acompanhou todas as buscas. No mesmo sentido são as declarações dos policiais na fase judicial, reiterando a narrativa acima. Ante o exposto, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação. A materialidade é comprovada pelos documentos de fls.1/33 (auto de prisão), fls.74/75 (laudo) e pela prova oral. De igual forma a autoria restou comprovada, recaindo na pessoa do

acusado. Ressalte-se a confissão judicial, merecendo destaque a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual: "...a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. – 14 ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2003, p. 288). No mesmo caminho segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado: "A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório, não pairando dúvidas quanto à prática delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador a pesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso." (Apelação Criminal 990.09.274150-0 – 14ª Câmara de Direito Criminal – Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi – Data de registro 23/04/2010). Ademais, a prova dos autos demonstra que o entorpecente apreendido pertencia ao acusado e se destinava ao comércio ilícito, e não apenas ao consumo próprio, mormente pelas condições da abordagem. Ademais, os policiais foram taxativos em afirmar que se deslocaram ao local para apurar ocorrência de violência doméstica, na qual constava o nome do acusado, indicando que no local ele armazenava arma de fogo e entorpecentes. Notando a presença da viatura o acusado empreendeu fuga, mas foi contido. Durante as buscas, inclusive com o apoio de cães farejadores, apreenderam várias porções de maconha e dinheiro. Ademais, os policiais foram incisivos em afirmar que o acusado confessou a prática do narcotráfico, assumindo a propriedade das drogas e indicando o valor que praticava. Ressalto que além da droga apreendida, para a solução do delito em tela outras circunstâncias são observadas, tais como o local da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, a denúncia pretérita, etc. Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida do acusado, no caso, não tendo sido trazidos aos autos elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de poder incursionar pela seara do uso de drogas. Também não restou comprovada a origem lícita do numerário apreendido. Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado. Quanto ao valor dos depoimentos de policiais, como são servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade (o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir o crime), presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade, mormente porque não há nos autos nenhuma notícia de que teriam motivo para imputar acusação falsa ao réu, que sequer conheciam. Aliás, como já se decidiu, "Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão não impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos pequeno valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos usuários da fase inquisitorial" (TJ-DF, Ap. 20030110632367APR, 1ª T., Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p. 180). No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha

participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada" (STJ, HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304). "Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - Materialidade delitiva e autoria demonstradas. A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei. Prova - Palavras de Servidores Públicos - Validade - Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente. Penas fixadas acima do mínimo legal, em razão da reincidência. Regime prisional fechado. Recurso provido" (TJ-SP, Apelação nº 0010112-19.2016.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Machado de Andrade, v.u., j. 5 de julho de 2018). Vale ressaltar ainda que para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato do réu armazenar os entorpecentes apreendidos, com o objetivo de comercializá-los, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse contexto, comprovadas a autoria e materialidade, passo à dosimetria das penas. Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem a fixação de pena maior, fixo-a no piso, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo a unidade. Na segunda fase incide a agravante da reincidência (fls. 130/131), contudo, fica compensada pela atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena no piso. Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585 firmou a tese que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" e o relator do tema, Min. Sebastião Reis Junior, proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Ora, neste caso, o acusado ostenta outra condenação, sendo reincidente, logo, fica afastada a aplicação do redutor. Vale ressaltar que a reincidência deve ser utilizada tanto para agravar a pena na segunda fase, como para afastar a incidência do redutor previsto na Lei de Drogas e isto não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, conforme reiteradas decisões do C. Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MODO FECHADO ADEQUADO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a

atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Reconhecida pela Corte de origem a reincidência do paciente, torna-se incabível a aplicação da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Precedente. 4. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada

em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes. (...) 7. Habeas corpus não conhecido" (HC 391152/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 18/04/2017, De 25/04/2017, grifo meu). Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, fica definitiva a pena acima lançada. Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Além de ostentar outra condenação, sendo reincidente, o acusado foi surpreendido com grande quantidade de drogas, indicando que fazia do crime seu meio de vida, de sorte que a gravidade concreta do delito se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. O réu está preso. Nego o direito ao recurso em liberdade. O crime que cometeu e a pena a que está submetido, nesta sentença, são suficientes para retratar sua periculosidade se solto, de modo que a prisão se sustenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, trata-se de réu reincidente em tráfico de drogas e como permaneceu preso durante a tramitação do processo, seria um contrassenso que, sem o primeiro título de condenação, a sentença, houvesse motivo para manutenção do cárcere. E, depois, com a definição da culpa (ou pelo menos a primeira definição rumo à culpa), tivesse o direito de deixar a prisão. Assim, já se decidiu: "Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. (...) Direito de apelar em liberdade. Réu que permaneceu custodiado ao longo do processo. Prisão preventiva. Fundamentação. I - O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. (Precedentes do STJ e do STF). II - A exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (Súmula n. 09 do STJ). (...) III - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautela (Precedentes). Writ denegado" (HC 62882/RS; Ministro Felix Fischer, j. 07/11/2006, DJ 12.02.2007, p.285). O presente caso não comporta aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, com a prisão provisória, ainda não alcançou o tempo que lhe permitiria a progressão de regime. Ante ao exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o réu JOSÉ PEDRO FRANCO DE LIMA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo a unidade. Cada dia-multa deverá ser calculado sobre um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal. Como exposto acima, sem direito a recurso em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Condeno-o ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 105). Comprovado o tráfico de drogas, decreto o perdimento do numerário apreendido, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, não foi comprovada a origem lícita do bem apreendido. Agora, com a sentença decretada, estando o laudo definitivo da droga nos autos, determino a destruição da contraprova armazenada, servindo esta como ofício. Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). Em seguida, o(a) acusado(a) declarou que NÃO deseja RECORRER DA SENTENÇA, tendo seu defensor declarado que irá analisar. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara,

M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente